



第二讲

交易成本、科斯定理与 国家行为的法律边界

市场失灵 → 国家干预

国家-市场-法律三者关系

案例讨论 (之一)

- 苹果产品保修规定的争议 保修期不重新起算.
违反三包规定. 保修期只有一年
- 思考:
 - (1) 消费者权利是否受到了侵害?
 - (2) 强制性的“三包规定”是否提升了消费者的权益?
- 类似的制度: 电商的七天无理由退货规则
有的消费者从来不退. 所以不买这个服务. 但现在必须为此付费

案例讨论（之二）

- 饭店“霸王条款”的合法性争议
- 思考：
 - (1) 消费者权利是否受到了侵害？
 - (2) 司法政策是否提升了消费者的权益？

分析

- 讨论的前提：自由缔结的合同
- 问题：自由缔结的合同什么时候无效？
- 合同法：首先那些条款必须双方都知情
- --违反法律、行政法规的强制性规定
- --违背公序良俗
- --恶意串通损害他人合法权益
- 如何看待《消法》？何谓“霸王条款”？
本意是保护消费者，有强制性规定，却反而减少了消费者的选择，增加了消费者成本

	合同1	合同2		合同N
条款1（价格）	5000元	5500元		
条款2（保修期）	1年	2年		
条款3				
条款4				
条款5				
.....				
条款N				

	合同1	合同2	合同3		合同N
条款1（价格）	200元	300元	400元	充分竞争的市场经济环境下 各家利润率应该都差不多	
条款2（是否允许自带酒水）	不允许	允许	允许		
条款3（是否收取包间费）	收	收	不收	禁止霸王条款→司法一般认为是自由 缔结合同→而且这样会减少消费者的 选择,并提升其消费成本	
条款4					
条款5					
.....					
条款N					

小结

- 竞争发生在商家与商家之间，消费者与消费者之间，
而不是商家与消费者之间；
无法改变价格条款
- 强制性法律可以改变合同的一个条款，却无法改变合同的全部条款；
利益不会因法律规定凭空产生
- 强制性法律无法改变市场供求关系，因此不可能给消费者提供额外的利益，反而会减损消费者的利益；
- 政府应当做的事情：不是强制性改变合同条款，而是确保自由的市场准入，这才是消费者保护的根本所在；
更多的资本、更多的商家形成更充分的竞争才能更好保护消费者权益
- 关于产品质量监管：强制性法律对消费者有时候是有害的（三鹿奶粉）
为达到规定不择手段
- 尝试分析消费者无理由退货规定的合理性 *买家愿以卖家愿，消费者在信息上处于劣势*
法律上消费者与商家是对立的，但现实市场两者是合作→双方都觉得有利可图才会达成交易。竞争是在商家与商家之间。消法把商家与消费者当作互相竞争的对立关系

思考

- 如何用一个“通用”的理论模型来解释各种经济法律现象？ 金融监管、环境保护、反垄断、劳动者权益……
- 法律概念和法律条文的有限性 现实生活要丰富得多
- 超越法律：“交易成本（transaction cost）”观念的引入

罗纳德·科斯 (Ronald Coase)

Ronald Coase (1910-2013)

两篇传世论文 (对经济学和法学来说都是具有里程碑意义的作品)
企业为什么要存在? → 市场的不完美

The Nature of the Firm, 1937

组织成本 vs 交易成本 计划经济组织成本过高

The Problem of Social Cost, 1960

出价高的人获得稀缺资源? (X) 国家不需要参与分配

1991年诺贝尔经济学奖



最重要的理论贡献: 交易成本 (transaction cost) 的观念

vs 建构主义 - 抽象逻辑推导

研究方法上的启示: 直面真实世界的经济现象, 经验主义的路径

公共产品需要国家力量建设而不能靠市场 (X) 灯塔建了不能保证受益人只有自己因此都等别人建

↓
理论上很有道理 → 科斯去查英国第一座灯塔谁建的。

英文法学期刊中被引用频率最高的单篇论文

英文法学期刊中被引用频率最高的单篇论文？

科斯 (1960) : 《社会成本问题》

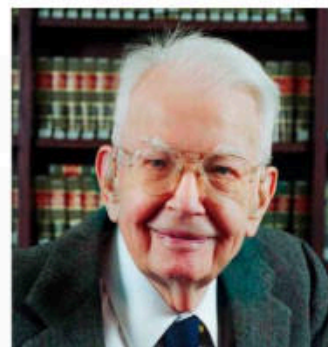


TABLE I.
MOST-CITED LAW REVIEW ARTICLES OF ALL TIME
COMPILED BY FRED R. SHAPIRO

1. 5157 R.H. Coase, *The Problem of Social Cost*, 3 J.L. & ECON. 1 (1960).
2. 3678 Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, *The Right to Privacy*, 4 HARV. L. REV. 193 (1890).
3. 3138 O.W. Holmes, *The Path of the Law*, 10 HARV. L. REV. 457 (1897).
4. 2771 Gerald Gunther, *The Supreme Court, 1971 Term—Foreword: In Search of Evolving Doctrine on a Changing Court: A Model for a Newer Equal Protection*, 86 HARV. L. REV. 1 (1972).
5. 2343 Herbert Wechsler, *Toward Neutral Principles of Constitutional Law*, 73 HARV. L. REV. 1 (1959).
6. 1980 Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, 85 HARV. L. REV. 1089 (1972).
7. 1874 Charles A. Reich, *The New Property*, 73 YALE L.J. 733 (1964).
8. 1794 Charles R. Lawrence III, *The Id, the Ego, and Equal Protection: Reckoning with Unconscious Racism*, 39 STAN. L. REV. 317 (1987).
9. 1701 William J. Brennan, Jr., *State Constitutions and the Protection of Individual Rights*, 90 HARV. L. REV. 489 (1977).
10. 1653 Robert H. Bork, *Neutral Principles and Some First Amendment Problems*, 47 IND. L.J. 1 (1971).

The Problem of Social Cost

从“牛吃麦”的故事开始

两户相邻人家：一户种地，一户养牛；牛会跑到麦地里乱踩、偷吃

传统法学的观点：养牛人侵犯了农民的权利，因此需要通过侵权损害赔偿来防止社会损害的出现

(暗含了道德评价，侵权人的行为是不正当的，需要被制止的)

福利经济学家庇古 (Pigou)：存在外部性 (externality) 问题，市场失灵

所以需要国家干预： (1) 税收； (2) 侵权损害赔偿

科斯：为什么一定是养牛人侵犯了农民的权利，而不是农民侵犯了养牛人的权利？

——权利的相互性 (reciprocal nature)

The Problem of Social Cost

分别比较两种权利界定方式的现实后果 对社会财富到底有何影响?

1. 权利界定给农民，牛吃麦要赔偿
2. 权利界定给养牛人，牛吃麦不需要赔偿

假定：养牛的收益是**400**，种麦子的收益是**200**

假定：牛吃麦子导致的损失是**100**，建一个围栏把牛圈起来的费用是**50**

The Problem of Social Cost

第一种情况：权利界定给农民，牛吃麦要赔偿（成文法或者司法判例）

农民的收益是200

放牛人两个选择：（1）让牛去吃麦子，赔给农民100，则最终收益 $400-100=300$

（2）花50建一个围栏，最终收益 $400-50=350$ 显然放牛人会选择建围栏

社会总收益： $200+350=550$

第二种情况：权利界定给养牛人，牛吃麦不需要赔偿

养牛人：放任牛吃麦，收益400；则农民收益 $200-100=100$

实际上，农民会和养牛人协商，付给后者50，建围栏

最终结果：农民收益 $200-50=150$ 社会总收益 $400+150=550$

The Problem of Social Cost

只要权利清晰地配置给某人，市场会自发调节

结论：无论权利界定给谁，对最终的资源配置结果（效率）没有影响

(科斯定理) (初学结论)

前提：交易成本为零（农民和养牛人之间的谈判是没有成本的）

单一所有者 (single owner) 假定：你同时是养牛人和农民

你的行为选择：花50建围栏，个人收益（等于社会收益）550

(农民收成低了单价就高了)
在市场的交易中也可以化解。

顺便解释：不同的权利配置是否对农民和养牛人个体利益有影响？

↑
✓ 对个体收益有影响
对社会收益无影响

只要法律是确定的，这个影响可以通过市场消解：
农民和地主之间；养牛人和买牛人之间

科斯给出的其他例子：铁路和农田；牙医和糖果制造商

牙医和糖果制造商

法院判决糖果制造商侵权成立，停止生产

假定：因为糖果制造商停止侵权行为，牙医避免**500**损失

糖果制造商的生产收益是**1000**

假定交易成本为零，双方进行谈判，结果都是糖果制造商继续生产

可能的方案：1. 糖果制造商补偿牙医搬迁费用（搬家费+营业损失），不超过**1000**

2. 牙医停业，糖果制造商给予 **(500,1000)** 区间内的补偿

3. 糖果制造商出钱，建一堵隔音墙，不超过**1000**

——初始权利配置不影响资源配置的效率

用“单一所有人”理念来分析：生产糖果还是拔牙？——生产糖果

另一个例子

工厂排放烟尘，污染周围五户居民晾晒的衣服

污染的损失每户**75**，一共**375**

两种解决方案：其一，工厂安装滤尘器，花费**150**；其二，每户居民安装干洗机，每户**50**，一共花费**250**

哪一种方案社会收益最大？安装滤尘器

探讨不同的权利配置格局：

1. 居民有享受洁净空气的权利

工厂的三种选择：（1）支付**375**的损害赔偿；（2）花费**150**装滤尘器；（3）花费**250**给每户人家配干洗机

显然工厂选择（2）安装滤尘器

另一个例子

2. 工厂有污染权

住户有三种选择：（1）承担**375**的损失；（2）花费**250**购买干洗机；（3）花费**150**去给工厂安装滤尘器

显然，住户选择方案（3）给工厂安装滤尘器

前提：交易成本为零，五家住户和工厂可以进行谈判（科斯谈判）

科斯定理（由**George Stigler**总结的）

如果交易成本为零，不论法律规则如何选择，资源配置的效果都是一样的

科斯赞同科斯定理吗？

如何理解交易成本为零的假设？（如何理解物理学上摩擦力为零的假设？）

真实世界：存在交易成本

五户人家去找工厂谈判，需要互相联络，需要花费时间，有人要搭便车

假定每户人家的成本是60

第一种情况：住户享有清洁空气权

结果还是：工厂安装滤尘器

第二种情况：工厂有污染权

无交易成本的情况下，五户人家共同出资150为工厂安装滤尘器

有交易成本（每户60），每户人家的选择（1）承受75的损失；（2）花50买干洗机；（3）和其他住户一起为工厂买滤尘器，花费 $30+60=90$

住户会选择（2）买干洗机。

真实世界：存在交易成本

企业会自主安装吸尘器

因此存在交易成本的情况下，住户享有清洁空气权是有效率的（社会收益最大）；
但是，工厂有污染权是无效率的。所以法律应该把权利配置给住户。

住户与工厂去谈判

科斯定理的引申：**存在交易费用的情形下，应当选取能够使得交易成本最小化的法律规则**

科斯理论的真谛

以“交易成本”为出发点思考法律制度

(一) 交易成本为零或者交易成本很低的情况下，权利的初始配置不重要
强调市场机制的作用，尊重当事方之间的自由意志

符合“卡尔多-希克斯效率”，例如契约自由原则的应用

讨论：为什么法律不禁止拳击比赛（通过契约转让身体权利），但法律却要明确地把人身权界定给每个人自身？ 保证人意志自由，促进创新。

举例：《物权法》第七十四条：建筑规划内，规划用于停放汽车的车位，车库的归属，由当事人通过出售、出租或者附赠等方式约定。

如约定车库归业主，则房价提高；如约定归开发商，则房价减少

初始权利分配不影响资源配置的结果

房屋租赁的强制规定？不能高于...
供求关系不变，房东用各种手段去规避

以“交易成本”为出发点思考法律制度

(二) 交易成本较高时，则由法律来界定权利归属，原则：社会成本最小，产出最大

通常情况下，为什么坚持“物权法定主义”？

物权法律关系和合同法律关系的差别在哪里？

类似地，人身权由法律直接界定 和世上其他所有人达成协议成本极其高昂

讨论：“买卖不破租赁”原则 保护弱势群体？

不动产买卖交易之后，权利可能界定给买受人，也可能界定给租赁人

按照科斯定理，界定给谁，后果都一样

现实情况：存在交易成本，租赁人在租赁的时候不可能与所有潜在的买受人进行谈判

为什么把初始权利界定给租赁人？买受人可调查房屋的租赁情况，^{EX: 房东的房子要卖，搬走也是有成本的}以保证自身的交易安全；若权利配置给买受人，则其可利用租赁人的沉没成本以“逼迁”获取利益，社会成本很高

买受人可以随意提升租金

以“交易成本”为出发点思考法律制度

当交易成本^{极高}阻碍交易发生时，可由法律拟制一种市场交易情形

拟制交易的原则：卡尔多-希克斯效率，即“社会财富最大化”

正当防卫，紧急避险^{小成本换取大的收益}
共同海损^{海上救助协议→紧急情况}
海上救助^{各个商家要一起谈判，但现实中这种谈判不能发生，船长自主决定}
法律规定大家一起补偿货物被扣的商家（不需要谈判）
^{契约显失公平。}

国家紧急状态法（战时、灾难）：搁置议会（法律强制替代交易机制）
^{EX：公司法中上市公司回购小股东的股份→新股东充分竞争（卖不掉）价格由法院确定}

行政法上的比例原则：国家与公民之间关系的非契约处理方式

讨论：“钉子户”问题，可否强拆（法律拟制市场交易）
^{如何新的交易成本导致国家介入}

一对一的交易可否强制？^(X)强拆：一个开发商，多户居民

拆迁不是对一交易，谈判是一多多的进行，所有人都希望自己最后一个去谈，前期成本投入非常高昂不能白费，这时候就可以狮子大开口→谈判地位极其不对等，交易成本过高导致交易无法发生→强制交易（法律拟制率的交易）

加装电梯→本多数决
也是法律拟制契约

或者上市公司退市要回购所有股份→剩下一生股份
不省变→强制交易

思考

- 如何用“交易成本”的逻辑解释“苹果保修”案例和“饭店霸王条款”案例？
- 公权力（市场监管部门、法院）介入交易的正当性是否存在？
- 标准：交易成本是否足够高以至于消费者的权利无法用契约来保护？(X)
- 初始权利界定给谁重要吗？（是否需要公共部门强制性规定特定交易条件？）

国家、市场和法律的关系

- 法律的功能：*清晰的产权界定（法律制度）+ 事后救济。*
- 降低交易成本，尽可能让市场发挥作用
- 交易成本较高，法律提供国家介入市场的可能性，但要权衡交易成本与管制成本（永远的问题：代价是什么？）
- 在多种规制/管制手段可能介入时，要比较各种手段的制度成本
- 限定国家介入市场的行为边界，追究“越权”的法律责任（国家作为“必要的恶”）

破坏市场的交易自由，但市场不完美又是必要

思考题

- 一个真实案例：2015年9月，有用户使用蚂蚁花呗的赊账消费功能后逾期未还款，花呗的催收人员在该欠款人支付宝的记录上发现，欠款人给第三方送过粽子，收货人信息留有该第三方的联系电话。由于通过用户的绑定手机一直无法联系到用户本人，花呗工作人员就电话联系到了这个第三方，要求其协助联系欠款人。后者之后在知乎上发帖质疑蚂蚁花呗此举“侵犯了个人隐私”。
- 问题：是否需要通过国家立法，限制催收的手段，以保护消费者的隐私/信息权利？

导致贷款利率更高？反而伤害消费者利益